

1500779-44.2020.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... havia se deparado com o acusado em ponto de tráfico. Porém, nunca o havia detido. Não conhecia o motociclista, que sequer é de Bauru e informou que estava naquela data de passagem. O local da prisão é o ponto mais forte de tráfico do bairro (fls. 160/164).

A testemunha Matheus Moreira da Costa disse que saiu do trabalho por volta das duas e meia. Estava com problemas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500779-44.2020.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500779-44.2020.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2195856/2020 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 12911581 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 10204/20/404 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2195856 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WESLEY DOS SANTOS CLARO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

WESLEY DOS SANTOS CLARO foi dado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 10 de agosto de 2020, por volta das 15h40, na rua Natal Fornazari, 2-02, Jardim Country Club, nesta cidade, trazia consigo, para fins de tráfico, 22 porções de cocaína embaladas em invólucros plásticos do tipo 'eppendorfs' de cor rosa com peso de 3,72 gramas, bem como vendeu 02 porções de cocaína embaladas em invólucros plásticos do tipo 'eppendorfs' de cor rosa com peso de 0,35 gramas, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, e tinha consigo, ainda, o valor de R\$ 60,00, em cédulas de R\$ 20,00 e R\$ 10,00.

Notificado (fls. 82), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 117/118. A denúncia foi recebida por despacho datado de 27 de novembro de 2.020 (fls. 120/122).

Em audiência, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 153/174). Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 186/189).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 194/227, alegando que: 1)- a confissão restou isolada; 2)- as provas são frágeis; 3)- o réu faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas; 4)- a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritiva de direitos. Pediu a absolvição e, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, a fixação do regime inicial aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 27 e pelo laudo pericial de fls. 175/178 (vinte e duas porções de cocaína com peso de 3,72 gramas e duas porções de cocaína com peso de 0,35 gramas).

A autoria e o intuito de traficância derivam da prova oral e das circunstâncias do caso e devem ser atribuídos ao acusado.

Em juízo, a testemunha João Roberto Gonzaga de Lima, policial militar, afirmou que estava em patrulhamento pelo bairro com o fim de coibir o tráfico de drogas. Ao acessar a via em questão, viu o réu entregando um objeto para o condutor de uma moto. Os dois indivíduos, ao verem a viatura, tentaram correr, mas foram contidos. Realizada busca pessoal em Wesley, foram encontrados pouco mais de vinte porções de cocaína, em suas roupas íntimas. Com o condutor da moto, havia outros dois pinos de cocaína idênticos àqueles mais de vinte. O motociclista, quando questionado, disse ter adquirido a droga do réu. Este, por sua vez, nada quis dizer mas, quando tomou ciência de que seria conduzido ao plantão policial, entrou em luta corporal com os policiais. Foi necessário força para algemá-lo. O condutor da moto tentou correr ao mesmo tempo e também entrou em luta corporal, mas foi igualmente contido depois de os policiais utilizarem-se de muita força. Inicialmente, viu a moto estacionada em frente ao meio fio, estando o condutor sobre ela, numa situação de "parada rápida". O acusado estava a pé, na calçada, entregando um objeto para o outro. Salvo engano, segundo o motociclista, ele já havia feito o pagamento. Havia dinheiro em poder do réu, mas não se lembra da quantidade. Não se recorda da cor dos pinos, mas eram todos idênticos. Já havia se deparado com o acusado em ponto de tráfico. Porém, nunca o havia detido. Não conhecia o motociclista, que sequer é de Bauru e informou que estava naquela data de passagem. O local da prisão é o ponto mais forte de tráfico do bairro (fls. 160/164).

A testemunha Matheus Moreira da Costa disse que saiu do trabalho por volta das duas e meia. Estava com problemas familiares e resolveu comprar entorpecentes como válvula de escape. Quando comprava as drogas, a viatura apareceu. Comprou dois pinos e pagou vinte reais. Já tinha entregado o dinheiro ao réu. Foi conduzido para a delegacia (fls. 166/167).

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática do delito. Disse que errou em ter feito "essas coisas". Não precisava traficar pois seu pessoal sempre dá uma força. Atualmente está "de boa" e trabalhando. Era a primeira vez que vendia drogas no local. As porções vendidas para Matheus foram as primeiras comercializadas naquele dia. Está trabalhando com transporte e com registro em carteira (fls. 169/172). Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa.

O fato e sua autoria estão bem demonstrados.

Com efeito, o réu confessou a prática do crime em juízo, livre de qualquer forma de pressão ou coação.

A mera confissão judicial já seria elemento de prova bastante para a condenação, mesmo porque nada indica tenha sido o réu insincero ao se autoincriminar.

Nesse sentido:

"Prova. Confissão judicial. Único elemento de prova a embasar a condenação. Admissibilidade. A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquela em que lhe evidencie a insinceridade, ou quanto tiver prova veemente em contrário." (TJSP, RT 744/573). De qualquer forma, a confissão não está isolada no conjunto probatório. Ao contrário, a prática do delito foi também confirmada pelo depoimento insuspeito de um policial militar, que flagrou a transação ilícita, bem como pelas declarações da testemunha Matheus, que informou ter acabado de adquirir entorpecente do acusado quando do surgimento da viatura policial. Note-se que as afirmações do policial se afiguram firmes, coerentes, comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de policiais.

A propósito:

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369). Quanto às declarações da testemunha Matheus, devem ser tidas igualmente por imparciais, na medida em que, sequer tendo sido o responsável pela prisão, não teria motivos para falsear a verdade em detrimento do réu.

Enfim, o fato descrito na denúncia e respectiva autoria estão bem demonstrados.

Por outro lado, não há dúvida de que o acusado estava praticando o tráfico.

Isto porque, conforme vem da prova, ele foi flagrado em pleno ato de mercancia espúria, fato ocorrido em local de tráfico intenso, e estava na posse não somente de pinos de cocaína idênticos aos entregues ao comprador como também de dinheiro. Destarte, não há como absolver, e nem mesmo como desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.

Em suma, a condenação do réu na forma proposta na denúncia é medida de justiça.

Passa-se à aplicação da pena.

O réu não tem antecedentes criminais (fls. 42).

Diante disso, fixa-se a pena base no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão, mais quinhentos dias-multa.

As atenuantes da confissão e da menoridade relativa não têm repercussão na redefinição do montante da pena, uma vez que já estabelecida ela no mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Deve ser aplicado o privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11343/2006.

Com efeito, as quantidades de droga e de dinheiro apreendidas foram pequenas, não sendo possível inferir, a partir daí, que o réu se dedicava a atividade criminosa. Ademais, nenhum outro elemento dos autos permite concluir tratar-se de indivíduo dedicado a atividade criminosa ou integrante de organização criminosa.

É certo que o réu registra processo para apuração de ato infracional quando adolescente (fls. 43).

Não menos certo, porém, é que condenações na adolescência não devem redundar em empecilho ao benefício.

Este juízo vinha deixando de aplicar o privilégio para réus com condenação por ato infracional – a evidenciar dedicação a atividade criminosa –, com base em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e por entender ser necessário, a bem da segurança jurídica e do prestígio ao princípio da igualdade, seguir a orientação de Tribunais Superiores.

Ocorre, porém, que, o Supremo Tribunal Federal tem adotado entendimento em sentido contrário, ou seja, não é possível levar em conta prática de atos infracionais pretéritos para fins de afastamento da causa de diminuição.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE

DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO. ATOS INFRACIONAIS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) A prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Como disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas (arts. 1º e 112) e visam à proteção integral do adolescente infrator." (STF. Habeas Corpus 184.979/ES, j. em 08/05/2020. Relatora Ministra Carmen Lúcia).

E, ainda:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA (§ 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006). QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A NEGAR O REDUTOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ORDEM CONCEDIDA PARA SE REFAZER A DOSIMETRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A prática anterior de atos infracionais pelo paciente não configura fundamentação idônea a afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006." (STF. Ag. Reg. Em Habeas Corpus 191.992/SP, j. em 08/04/2021. Relator: Ministro Edson Fachin).

Nessa conformidade, não se poder dizer que o réu se dedica a atividades criminosas, apenas em razão de ostentar ato infracional pretérito.

Do contrário, haveria não somente ofensa ao princípio da inimizabilidade penal dos menores de dezoito anos, previsto no texto constitucional (art. 228 da CF), como também ao princípio da proteção integral de criança e do adolescente, dada sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (arts. 3º e 121 da Lei 8.069/90). Não bastasse, a utilização dos registros de jovens infratores em processos posteriores, quando de sua fase adulta, é vedada pelo item 21.2 das Regras Mínimas das Nações Unidas para Administração da Justiça da Infância e Juventude (Regras de Pequim).

Em que pese se tratar de Resolução da Assembleia Geral da ONU e, portanto, instrumento não vinculante, pode-se adotá-la enquanto orientação na aplicação do direito nacional.

Destarte, a partir da existência de registros de atos infracionais não se pode concluir que se está diante, aqui, de agente dedicado a atividades criminosas. Afigura-se justo deferir a diminuição no grau máximo de dois terços, tendo em vista que as quantidades de drogas e de dinheiro apreendidas foram, como visto, pequenas. Destarte, a pena resulta em um ano e oito meses de reclusão, mais cento e sessenta e seis dias-multa.

Não existindo outras modificadoras, tais penas são definitivas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena para o tráfico, deve-se ponderar que, no julgamento do HC n. 111.840/ES, realizado em sessão extraordinária do dia 27/06/2012, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e outros a eles equiparados (os dados são do HC n. 312.654-SP, STJ, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 12/02/2015).

Ainda, no julgamento do Habeas Corpus n. 137458/SP, o Ministro Gilmar Mendes assim dissertou:

"Destaco que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto, atentando-se aos preceitos estabelecidos no art. 33, § 2º, do Código Penal. Assim, não sendo a paciente reincidente, nem tendo contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP), a hediondez do crime não constitui motivação idônea a justificar a fixação do regime mais gravoso. Fixo, ainda, o regime aberto de início do cumprimento da pena".

Assim, ausente a obrigatoriedade de fixação do regime inicial fechado para o

tráfico, cabe analisar as circunstâncias do caso concreto, a fim de se definir o regime no qual o acusado começará a cumprir a sanção. Considerando as circunstâncias expostas (primariedade, ausência de antecedentes, pequenas quantidades de dinheiro e de drogas), fixa-se o regime inicial aberto. Levando em conta as circunstâncias judiciais favoráveis, conforme antes apontado e, ainda, o fato de as quantidades de droga e de dinheiro terem sido diminutas, entende-se cabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

Há orientação jurisprudencial nesse sentido:

“Tráfico de drogas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Elementos de prova suficientes para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Pena-base fixada no mínimo legal. Causa de aumento, prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, que não se afigurou. Afastamento. Réus que preenchem os requisitos para a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Circunstâncias do crime que tornam proporcional a diminuição na fração máxima de 2/3. Fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão, ex officio, da pena reclusiva em restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Detração determinada. Analogia ao artigo 42 do CP. Apelo parcialmente provido para esses fins. (TJSP, Apelação n. 0070062-66.2010.8.26.0050, rel. Otávio de Almeida Toledo, j. 13/12/2011).

Assim, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo das penas aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenar o acusado Wesley dos Santos Claro como incurso nas penas do artigo 33, caput e §4º, da Lei 11.343/2006, a cumprir um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar cento e sessenta e seis dias-multa, calculado o valor do dia multa no piso mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução.

Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

Declaro a perda em favor da União, e a reversão ao Funad, do numerário em dinheiro apreendido nos autos, nos termos do art. 91, II, “b”, do Código Penal, e art. 63, § 1º, da Lei n. 11.343/2006.

P.R.I.

Bauru, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA